

0001221-47.2018.8.26.0338

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Estelionato

Magistrado: LARISSA BONI VALIERIS

Comarca: Mairiporã

Foro: Foro de Mairiporã

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 01/06/2022

... REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO. PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. LICENÇA DE SAÚDE. ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO. ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Embora o § 2º do art. 399 do Código de Processo Penal disponha que "O juiz que presidiu a instrução deverá proferir a sentença", o preceito ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mairiporã

2ª Vara JUDICIAL

Rua Doutor José Adriano Marrey Jr., nº 780 - Centro - CEP: 07600-225 - Mairiporã - SP

Telefone: (11) 4419-5636 - E-mail: mairipora2@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

0001221-47.2018.8.26.0338 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0001221-47.2018.8.26.0338

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Estelionato

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Etevaldo Pinto Caldeiras

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Larissa Boni Valieris

Vistos.

ETEVALDO PINTO CALDEIRAS, já qualificado nos autos em epígrafe, foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 171, "caput", do Código Penal, porque, supostamente, no dia 04 de abril de 2016, em horário e local incertos, mas nesta cidade e Comarca de Mairiporã, o réu, teria obtido, para si, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo e mantendo as vítimas Nivaldo Soares de Souza, Cristiane Cassemiro de Souza, Felipe Souza de Oliveira e Luciana Garcia Zaccharias Oliveira em erro, mediante artifício, ardil e meio fraudulento.

Consta na denúncia (fls.113/115) que, segundo apurado, na época dos fatos, ETEVALDO, hipoteticamente, se dizia proprietário de um terreno situado na Estrada Existente, km 04, Mato Dentro/Terra Preta, com área de 2.000m². Após tratativas com as vítimas Nivaldo e Felipe, em tese, negociaram o imóvel pelo valor de R\$40.000,00 (quarenta mil reais). Finalizado o negócio, o réu, fraudulentamente, teria vendido o terreno mencionado para as mencionadas vítimas pela quantia de R\$40.000,00 (quarenta mil reais), sendo que, para pagamento, foi dado um cheque no valor de R\$20.000,00 (vinte mil reais) e o restante seria saldado em 40 parcelas de R\$ 500,00 (quinhentos reais). Assim, firmaram contrato particular de compra e venda (fls.28/30).

Contudo, ao tentar tomar a posse do imóvel recém adquirido, a vítima Nivaldo, teoricamente, não obteve êxito, sendo surpreendido por dois indivíduos (Pedro e José Pinto Soler), afirmando que a propriedade lhes pertencia. Ato contínuo, de acordo com o alegado, Nivaldo procurou o Cartório de Registro de Imóveis local,

momento em que descobriu que o imóvel estava registrado em nome de José Pinto Soler, revelando a falta de legitimidade do denunciado para negociar o imóvel. Assevera, a denúncia, que em razão do estelionato praticado pelo denunciado, as vítimas suportaram prejuízo de R\$20.000,00.

Decisão às fls.116 em que recebeu a denúncia.

Regularmente citado (fls.153), o réu, por intermédio de advogada dativa, apresentou defesa prévia às fls.160/161, pugnando pelo andamento do feito, para que sejam colhidas provas da inocência do réu em fase de instrução processual; ainda, arrolou as mesmas testemunhas do órgão ministerial.

Decisão às fls.162 em que ratificou o recebimento da denúncia.

O réu às fls.176/178, através de defensor constituído, arrolou testemunhas e requereu o benefício da justiça gratuita. Juntou documentos às fls.179/223.

O Ministério Público se manifestou às fls.226 apontando que as testemunhas não foram arroladas no momento cabível (fls. 160/161), e não sendo caso de substituição, está preclusa a prova testemunhal da defesa, razão pela qual aguarda o indeferimento do pedido de oitiva.

Decisão às fls.228 em que deferiu a inclusão das testemunhas.

A testemunha de defesa Jonas Severo de Lira foi ouvida por carta precatória às fls.327, oportunidade em que foi homologada a desistência da oitiva da testemunha Edson dos Santos.

Despacho às fls.415 em que designou audiência de instrução e julgamento.

Em audiência de instrução e julgamento (fls.467/468) foram ouvidas as vítimas e, em seguida, interrogado o réu.

O réu às fls.470/471 requereu a juntada de documentos. Documentos juntados às fls.472/478.

Manifestação do Ministério Público às fls.485 requerendo cópia da certidão de óbito da testemunha José Pinto, posteriormente, vista para eventual pedido de substituição da testemunha ou de desistência, ante a certidão de fls.482.

Despacho às fls.487 em que deferiu o pedido.

O Ministério Público às fls.494, ante a certidão de óbito de fls.490, apontou que não possui testemunha para indicar em substituição, aguardando, portanto, o encerramento da instrução processual.

Decisão às fls.495 em que declarou preclusa a produção da prova, determinando que as partes informem se pretendem a produção de outras provas ou se concordam com o encerramento da instrução.

Decisão às fls.498 em que diante da manifestação da acusação e inércia da defesa, declarou encerrada a instrução processual.

Em memoriais escritos às fls.503/507, o d. representante do Ministério Público requereu a procedência da ação, para condenar o réu nos termos da denúncia.

Observou, quanto à dosimetria, que o réu ostenta maus antecedentes e personalidade voltada para o crime; na segunda fase, presente a agravante da reincidência; na terceira fase da dosimetria, ausentes causas de aumento ou de diminuição da pena. Destarte, requereu o regime inicial fechado e entendeu incabível a substituição da pena por restritivas de direitos.

Em memoriais escritos às fls.512/530, a d. defesa, por seu turno, pugnou pela absolvição do réu das imputações que lhes são feitas, com a apreciação das preliminares arguidas, senão, por insuficiência de prova, com fulcro no artigo 386, inciso IV ou inciso VI, do Código de Processo Penal, ou ainda, com base na máxima que é "in dubio pro-reo", por ser da mais lúdima justiça.

Certidão de Antecedentes Criminais às fls.133/139 e 432/440, Folhas de Antecedentes às fls.123/132 e Certidão de Objeto e Pé às fls.414.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Presente os pressupostos processuais e as condições da ação, ausente, ainda quaisquer causas de nulidade que tenham ensejado prejuízos ao réu, passo ao exame do mérito.

Inicialmente, destaco se encontrar presente exceção à identidade física do juiz, tendo em vista que a DRA DANIELA AOKI DE ANDRADE MARIA se encontra em licença saúde. Sobre o tema:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO. PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. LICENÇA DE SAÚDE. ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO. ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Embora o § 2º do art. 399 do Código de Processo Penal disponha que "O juiz que presidiu a instrução deverá proferir a sentença", o preceito contido no referido dispositivo legal não pode ser aplicado de maneira absoluta, visto que a prestação jurisdicional dos togados investidos na competência para a apreciação e o julgamento de causas criminais passaria a ser, necessariamente, ininterrupta, impedindo-os de se afastar temporariamente de suas funções, seja por motivo de férias, de licença médica, de convocações, seja, até mesmo, de progressão funcional, o que é inerente à carreira. 2. Em razão da ausência de outras normas que regulamentam o disposto no referido artigo, esta Corte Superior de Justiça consolidou o entendimento de que é possível a mitigação do aludido princípio nos casos de convocação, licença, promoção, aposentadoria ou de qualquer outro motivo que impeça o juiz que houver presidido a instrução de sentenciar o feito. Aplica-se, por analogia (permitida pelo art. 3º do Código de Processo Penal), o art. 132 do Código de Processo Civil. 3. O rol constante no art. 132 do CPC não é taxativo – haja vista a expressão "afastado por qualquer motivo", contida no caput –, razão pela qual a substituição é admitida também na hipótese de licença de saúde, tal como ocorreu no caso. 4. Para a caracterização do delito previsto no art. 35 da Lei de Drogas, é necessário que o animus associativo seja efetivamente provado. Isso porque, se assim não fosse, estaria evidenciado mero concurso de agentes para a prática do crime de tráfico de drogas. 5. O Tribunal de origem – dentro do seu livre convencimento motivado – apontou elementos concretos, constantes dos autos, que efetivamente evidenciam a estabilidade e a permanência exigidas para a configuração do crime previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/2006. 6. Agravo regimental não provido. (Superior Tribunal de Justiça. Sexta Turma. AgRg no Agravo em Recurso Especial 1579227/MG (2019/0270624-1). Relator Min. Rogério Schietti Cruz, 28/04/2020).

Nesse passo, de pronto, anoto que a materialidade delitiva restou comprovada pelo Instrumento Particular de Compra e Venda (fls.28/30), Termo de Declarações (fls.38, 39, 40, 41, 75 e 97), Relatório Final (fls.87/89), bem como pelas provas orais colhidas.

De outro lado, a prova se revela idônea para demonstrar a autoria, eis que os elementos produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa se encontram em consonância com aqueles colhidos na fase inquisitorial, restando isolada a tese defensiva tecida pelo réu, que, em seu interrogatório, explanou que, vendeu o terreno para o Nivaldo, eram dois lotes por R\$ 40.000,00; recebeu R\$ 20.000,00 reais e o restante foi parcelado em 40 parcelas de R\$ 500,00, mas não recebeu; Nivaldo foi limpar o lote errado; o lote de Nivaldo está disponível para ele; há várias casas no local que foi o vendedor; era dono de um terreno grande, de 11 alqueires; comprou de uns herdeiros em 1985; foi vendendo as partes do imóvel; vendia "facilitado" para que os compradores pudessem legalizar o imóvel; o local é área rural; não falou para Nivaldo que iria devolver o dinheiro, disse que ele foi no lote errado; o terreno sempre foi seu; há moradores no local; Pedro Pinto Soler é seu vizinho, nunca vendeu terreno para ele; Nivaldo mexeu nas terras de Pedro; a assinatura da notificação não é sua; comprou o terreno de vários herdeiros; seu terreno não estava cadastrado no Cartório de Imóveis; vende imóvel do Incra, fração ideal; explicou para Nivaldo que não adiantava ir no cartório, pois não estava registrado e nem na prefeitura, que era apenas contrato de compra e venda; falou para Nivaldo fazer o Mapa Geo da área e ir até o cartório para fazer a escritura de direitos possessórios; avisou que não possuía escritura; não sabia que Pedro havia ido falar com Nivaldo; Nivaldo não foi lhe procurar; está tendo gasto para manter o terreno disponível; quem apresentou foi Sidney; não foi acionado de ação cível para reparação de danos; fez a transação comercial, que é a venda.

Com efeito, a vítima Luciana, narrou que, na época dos fatos, o tio do seu ex-marido (Felipe) estava procurando terrenos em Mairiporã, sendo que encontrou o réu para fazer negócio em um imóvel; acertou o pagamento de um valor à vista e os demais em parcelas; fizeram um contrato e assinaram; Nivaldo deu o dinheiro e no

momento que iria começar a pagar as parcelas, foi avisada por Nivaldo para que parasse de pagar, pois havia descoberto que o terreno não pertencia ao réu; foram acionados pelo proprietário do terreno; se dirigiram até a imobiliária de Mairiporã que explicou a situação; não fizeram o pagamento, apenas Nivaldo; não se recordou de valores, acha que R\$ 15.000,00; seu ex-marido que cuidou da parte de valores; foi até o terreno, mas não teve contato com a pessoa que se disse proprietária e nem haviam outras pessoas no imóvel; foi até o imóvel duas vezes; quem a levou foi Felipe; haveria uma divisão, Nivaldo ficaria com uma parte e seu ex-marido consigo ficaria com a outra parte; só participou da assinatura e do dia que foram visitar a área; havia casas perto; o dono da imobiliária que explicou o ocorrido; leu o contrato para assinar; não se sentiu lesada financeiramente, porque quando iria começar a pagar, descobriram; não teve contato com o réu.

Igualmente, a vítima Felipe, explicou que, na data dos fatos comprou um terreno do réu, e depois de uma ou duas semanas ficaram sabendo que o réu havia vendido um terreno que não era dele, confirmado pelo próprio proprietário do terreno; os vizinhos avisaram e ele veio conversar, perguntando por que estavam mexendo no terreno; falaram que haviam comprado o imóvel; descobriram então que o réu vendeu um terreno que não lhe pertencia; o proprietário conversou com Nivaldo; iria dividir o terreno com Nivaldo; Nivaldo pagou à vista a parte que lhe pertencia; iria pagar parcelado; depois dos fatos, não conversou mais com o réu; teve contato no máximo três vezes com o denunciado; leu o contrato; gastou pouca coisa com equipamento para limpar o terreno; Nivaldo teve o maior prejuízo por ter pago à vista sua parte no imóvel; é parente de Nivaldo; depois dos fatos, quem tratou dos assuntos foi Nivaldo; no dia que negociaram, o réu apontou que havia vendido um lote para outro rapaz; o réu mostrou alguns documentos para Nivaldo, mas confiaram no réu; conversaram com o réu primeiro na casa dele, depois foram até o terreno; não se recorda quem confeccionou o contrato, acha que foi o advogado do réu; não conheceu o advogado; no cartório, foi apenas o réu e os compradores.

Ainda, a vítima Nivaldo, aduziu que, em abril de 2016 conheceu o acusado, o qual lhe vendeu o imóvel mencionado, cerca de 2.000m²; fizeram a documentação; deu um cheque de R\$ 20.000,00; estava limpando o terreno, quando chegou o advogado que trabalhava com o dono da chácara, indagando se possuía documento; entregou a documentação e a pessoa falou que era falso; entrou com seu advogado; descobriu que o réu era estelionatário; na época, pagou R\$ 20.000,00 pelo terreno; fez transferência para a conta do réu; depois que descobriu que o terreno não era do réu, tentou conversar diversas vezes com o denunciado; o réu dizia que iria lhe pagar, mas não pagou; posteriormente, não conseguiu mais contato e descobriu que o réu havia ido para o Paraná; o denunciado dizia que o terreno lhe pertencia e que possuía documentação; viu a escritura do terreno e constava que era dos Pedrosos; não recuperou o dinheiro; quando descobriu que o terreno não era do réu, não verificou se no local existiam outros terrenos dele ou se outras pessoas da região se identificavam como compradores; quando começou a limpar, as pessoas diziam que não era para mexer, porque não pertencia ao réu; ficou sabendo por um amigo do réu, Sidney, que o terreno estaria a venda; conversaram sobre o terreno em Terra Preta, em uma espécie de fazenda e lá encontraram o réu; após, foram para o terreno; quando chegaram, o denunciado indicou o terreno que estava a venda; o réu mostrou outro lote que estava vendendo também, o fundo do imóvel que seria seu; fez contrato com o réu do terreno comprado; leu o contrato e estava claro; não vai até o terreno tem 2 anos; sabe onde poderia encontrar o réu.

De se ressaltar que o testemunho da vítima tem grande valor probatório em crimes desta espécie, eis que "em sede de crimes patrimoniais, os quais são praticados na clandestinidade, a palavra da vítima merece maior credibilidade que a versão sistematicamente negativa dos acusados, visto que não se concebe que alguém possa, gratuitamente, incriminar um desconhecido." (Revisão nº 224.054/3, Julgado em 10/03/1993, 5º Grupo de Câmaras, Relator: - Orlando Bastos, RJDTACRIM 18/194), ou seja, "a vítima do crime, em geral, é quem pode esclarecer, suficientemente, como e de que maneira teria ele ocorrido. Foi ela quem sofreu a ação delituosa, e, por isso mesmo, estará apta a prestar necessários esclarecimentos à justiça" (Processo Penal, 3º volume, Saraiva, São Paulo, 1993, p. 259).

De outra banda, a testemunha Jonas Severo, declarou que, é vizinho do réu; não acompanhou a negociação do terreno; não conhece quem seriam os donos; não conhece as vítimas; não conhece Pedro e José Pinto Soler; nunca soube de algo errado que o réu tenha feito no passado; não sabe de nada relacionado ao terreno; o local é zona rural; o réu tem uma chácara de 2.000 metros; não sabe se o réu é dono de mais imóveis; a área que mora não comprou do denunciado; não conhece o Sítio dos Pedrosos; não sabe se o réu vende terrenos; via que o réu cuidava de gados na propriedade dele.

Como se vê, o acusado incorreu na prática do crime de estelionato, tipo penal que protege o patrimônio, porquanto induziu as vítimas em erro, através de artifício ardil, de modo a obter vantagem econômica de R\$ 20.000,00, extraindo-se o dolo direto, tanto que se apresentou como titular do domínio de bem de terceiro, facilmente verificado pelos depoimentos e documentação amealhada aos autos, não podendo figurar como vendedor do imóvel em questão. Sobreleva notar que, o réu referiu, em juízo, que vendia de modo "facilitado", não possuindo documentação e tampouco cadastro nos órgãos competentes. Assim, de rigor a condenação do réu como incurso na pena do artigo 171, "caput", do Código Penal.

No mais, nota-se que o acusado detinha plena consciência da ilicitude de sua conduta, não havendo quaisquer excludentes de ilicitude ou de culpabilidade que possam beneficiá-lo.

Por conseguinte, em observância ao princípio da individualização da pena (artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal), o qual se respalda no critério trifásico proposto por Nelson Hungria, e adotado no artigo 68, do Código Penal, passo à dosimetria da pena.

Na primeira fase, atenta aos requisitos constantes do artigo 59, do Código Penal, observo que o réu ostenta Maus antecedentes (autos nº 0005607-72.2008.8.26.0338-fls.437/438); nada a valorar à culpabilidade, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, porquanto normais à espécie. Assim, fixo a pena base em 1 ano, 1 mês e 15 dias de reclusão e 11 dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria da pena, presente a circunstâncias agravantes da reincidência (autos 0012194-39.2010.8.26.0448 - fls.432/433) e a atenuante tipificada no artigo 65, inciso I, do Código Penal, uma vez que o réu é maior de 70 (setenta) anos na data da sentença. Destarte, mantenho a pena no patamar anterior. Na terceira fase da dosimetria da pena, ausentes causas de diminuição e aumento de pena. Logo, fixo a pena definitiva em 1 ano, 1 mês e 15 dias de reclusão e 11 dias-multa.

Ausentes elementos que denotam a capacidade econômica do réu, fixo o valor unitário do dia-multa no piso legal.

Ante as circunstâncias judiciais desfavoráveis e a reincidência, o regime inicial será o semiaberto, em exegese ao artigo 33, do Código Penal. Ademais, devido à reincidência, inviável a aplicação do artigo 44 ou 77, do Código Penal.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR o réu ETEVALDO PINTO CALDEIRAS ao cumprimento da pena de 1 ano, 1 mês e 15 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 11 dias-multa, no valor mínimo legal (artigo 49, "caput" e parágrafos do Código Penal), por restar incurso nas sanções do artigo 171, "caput", do Código Penal.

Ausentes os requisitos para substituição da pena, tendo em vista se tratar de réu reincidente e portador de Maus antecedentes; o que também se verifica em relação à suspensão condicional da pena.

O réu respondeu ao processo solto e poderá recorrer em liberdade, ausentes os requisitos para decretação de prisão preventiva, previstos nos artigos 312 e 313 do Código Processual Penal.

Custas e demais despesas pelo réu, ressalvada hipótese de gratuidade processual (artigo 804, do Código Processual Penal).

A complexidade da causa aliada à ausência de elementos suficientes sobre a quantificação dos prejuízos sofridos pelas vítimas, em princípio, não permite que esta magistrada fixe o valor mínimo para reparação dos danos, nos termos do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal. O referido dispositivo legal determina

que, para a fixação do valor mínimo a título de indenização, deve haver a apuração de quais foram os prejuízos sofridos. Logo, o montante indenizatório deve ser apurado sob o crivo do contraditório, com produção de provas suficientes para indicar a quantificação do dano, o que só se torna possível por meio de instrução probatória.

Nesse sentido: "AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. REPARAÇÃO DE DANOS. ART. 387, INC. IV, DO CPP. PEDIDO EXPRESSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO ESPECÍFICA. VIOLAÇÃO DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. I. A reparação de danos, além de pedido expresso, pressupõe a indicação de valor e prova suficiente a sustentá-lo, possibilitando ao réu o direito de defesa. Necessário, portanto, instrução específica para apurar o valor da indenização. II. Na hipótese, embora o Ministério Público tenha pleiteado expressamente na denúncia a fixação de valor para a reparação do dano, nos termos do art. 387, inc. IV, do CPP, não houve a instrução específica com a indicação de valores e provas suficientes a sustentá-lo, proporcionando a ré a possibilidade de se defender e produzir contraprova. III. Agravo regimental a que se nega provimento." (STJ, AgRg no REsp 1483846 / DF, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, Data do julgamento 23/02/2016, DJE 29/02/2016).

Comuniquem-se as vítimas sobre esta decisão (artigo 201, § 2º, do Código Processual Penal).

Transitada em julgado esta decisão:

Proceda-se à atualização da pena de multa, intimando-se a seguir o réu para o respectivo pagamento, nos termos do artigo 50, do Código Penal e artigo 686, do Código de Processo Penal;

Anote-se a suspensão dos direitos políticos do réu, a teor do inciso III, do artigo 15, da Constituição Federal;

Oficie-se ao Instituto de Identificação Civil do Estado, informando sobre a condenação do réu;

Expeça-se guia de execução penal.

Expeça-se certidão de honorários, se o caso.

Oportunamente, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo.

P.I.C., Mairiporã, 07 de Fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA